



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.009556/2018-28 (RJ2018/7211)

Data do julgamento: 18/02/2020

Diretora Relatora: Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Acusado: Hesa 101 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Henry Borenstein

Henrique Borenstein

Ementa: Oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro sem a obtenção do registro de que tratam os artigos 19, da Lei nº 6.385/76, e 2º, da Instrução CVM nº 400/2003, e sem a dispensa prevista nos artigos 19, §5º, inciso I, da Lei nº 6.385/76, e 4º, da Instrução CVM nº 400/2003. Advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Pela condenação da **Hesa 101 - Investimentos Imobiliários Ltda.** à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003;

2. Pela condenação de **Henry Borenstein** à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003;

3. Pela condenação de **Henrique Borenstein** à penalidade de

advertência, pela realização de oferta pública de distribuição de Contratos de Investimento Coletivo, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/76 e no art. 2º da Instrução CVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/76 e no art. 4º da Instrução CVM nº 400/2003.

O Colegiado decidiu pela comunicação do resultado do julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 28/2019, de 31.01.2019.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/2019.

Presente o advogado Rafael Salles, representante dos acusados.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi dos Santos, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 14/03/2020, às 21:58, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 16/03/2020, às 15:15, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 16/03/2020, às 19:27, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 17/03/2020, às 18:08, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0956297** e o código CRC **0640A6C5**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0956297** and the "Código CRC" **0640A6C5**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.009556/2018-28

(PAS CVM nº RJ2018/7211)

Reg. Col. 1402/19

Acusados: HESA 101 – Investimentos Imobiliários Ltda.

Henrique Borenstein

Henry Borenstein

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela realização de oferta pública de CICs hoteleiros sem a obtenção de registro ou dispensa.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários (“SRE” ou “Acusação”) em face de Hesa 101 – Investimentos Imobiliários Ltda. (“Hesa 101” ou “Incorporadora”) e de seus administradores, Henrique Borenstein e Henry Borenstein (ambos, em conjunto com a Incorporadora, “Acusados”), para apurar eventual responsabilidade pela realização de oferta pública de contratos de investimento coletivo (“CICs”), relativos ao empreendimento hoteleiro Park Inn by Radisson Santos (“Empreendimento”), sem a prévia obtenção do registro de que trata o art. 19 da Lei nº 6.385, de 07.12.1976¹, e o art. 2º da Instrução CVM (“ICVM”) nº 400, de 29.12.2003, e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I³, da Lei nº 6.385/1976, e no art. 4º da ICVM nº 400/2003.

2. Este PAS é oriundo dos Processos CVM nº RJ2015/6859 e SEI nº 19957.007000/2016-35, que versaram sobre a oferta pública de CICs relacionados com o Empreendimento.

¹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão.

² Art. 2º Toda oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos mercados primário e secundário, no território brasileiro, dirigida a pessoas naturais, jurídicas, fundo ou universalidade de direitos, residentes, domiciliados ou constituídos no Brasil, deverá ser submetida previamente a registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, nos termos desta Instrução.

³ Art. 19, § 5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: I - definir outras situações que configurem emissão pública, para fins de registro, assim como os casos em que este poderá ser dispensado, tendo em vista o interesse do público investidor; (...).

⁴ Art. 4º Considerando as características da oferta pública de distribuição de valores mobiliários, a CVM poderá, a seu critério e sempre observados o interesse público, a adequada informação e a proteção ao investidor, dispensar o registro ou alguns dos requisitos, inclusive divulgações, prazos e procedimentos previstos nesta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. FATOS

3. O Processo CVM nº RJ2015/6859⁵ foi instaurado pela SRE para analisar pedido de dispensa de registro de oferta pública de distribuição de CICs do Empreendimento⁶, protocolado na CVM, em 30.06.2015, pela Hesa 101, na qualidade de incorporadora, e pela Atlântica Hotels International (Brasil) Ltda. (“AHI” ou “Operadora Hoteleira”), na qualidade de administradora, para a distribuição de 241 unidades hoteleiras autônomas.

4. No pedido de dispensa, foi informada a estrutura contratual do investimento, com a celebração pela Hesa 101 e pelos adquirentes de Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Unidade Autônoma a ser Construída e Outras Avenças (“Contrato de Promessa de Venda e Compra”)⁷ e, depois de instituído o condomínio, seria criada uma sociedade em conta de participação, tendo a Operadora Hoteleira como sócia ostensiva e os adquirentes⁸ como sócios participantes. Com isso, a AHI celebraria Contrato de Locação⁹, por meio do qual locaria as unidades autônomas imobiliárias do Empreendimento.

5. Também foi informado à SRE que os CICs relativos ao Empreendimento já vinham sendo ofertados, inclusive que “**131 (cento e trinta e uma) Unidades Autônomas Imobiliárias já haviam sido vendidas**”, mas que a oferta tinha sido suspensa quando a Incorporadora e a Operadora Hoteleira tomaram conhecimento “*de que a alienação de Unidades Autônomas Imobiliárias poderia ser considerada uma oferta de contratos de investimento coletivo.*”¹⁰.

6. Após análise inicial do pedido de dispensa de registro, a SRE enviou à Hesa 101 ofício com comunicação acerca de exigências a serem cumpridas para apreciação do pleito, que incluía questionamento sobre “*o tratamento a ser dado aos adquirentes das 131 unidades autônomas já vendidas e se será concedida possibilidade de desistência do investimento (...)*”¹¹.

7. A resposta apresentada¹², em 23.09.2015, buscou demonstrar o atendimento das exigências relativas à concessão da dispensa de registro da oferta, bem como informou a retificação do “Prospecto Resumido” para reduzir o número de unidades da oferta de 241 para 77, de maneira

⁵ O Processo CVM nº RJ2015/6859 foi digitalizado e incorporado aos autos do Processo CVM SEI nº 19957.007000/2016-35, instaurado para apurar possíveis irregularidades na distribuição de CICs do Empreendimento. Para facilitar eventuais consultas, as referências feitas neste voto a documentos do Processo CVM nº RJ2015/6859 indicarão os docs. e fls. dos arquivos digitalizados constantes do Processo CVM SEI nº 19957.007000/2016-35.

⁶ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Docs. SEI 0524722 e 0524723, fls. 1-488.

⁷ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 16-86.

⁸ Esses assinariam o Termo de Adesão à SCP, Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 131a 155.

⁹ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 157-160.

¹⁰ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Docs. SEI 0524722 e 0524723, fls. 08.

¹¹ Ofício nº236/2015/CVM/SRE/GER-2, de 28.07.2015 - Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524723, fls. 491-500.

¹² Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524725, fls. 502-527.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

a excluir as 131 unidades previamente alienadas. Adicionalmente, foi reiterado que o Empreendimento havia sido lançado pela Incorporadora em setembro de 2013 e que teve suas vendas suspensas, voluntariamente, após a ciência de que a venda das unidades autônomas imobiliárias poderia ser considerada pela CVM como oferta de valor mobiliário. Quanto à possibilidade de desistência pelos adquirentes, foi informado que a Incorporadora não tinha recursos financeiros para tanto, pois mais da metade do Empreendimento já havia sido alienada.

8. As interações com a SRE prosseguiram até 18.12.2015, quando a área técnica comunicou à Hesa 101 a concessão da dispensa de registro de oferta pública de distribuição dos CICs¹³.

9. Em 05.04.2018, já no âmbito do Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, que tinha como objeto a apuração de eventual oferta irregular de valores mobiliários relativos ao Empreendimento, a SRE enviou ofício¹⁴ à Incorporadora e seus administradores para que se manifestassem sobre a possível oferta irregular de CICs relativos ao Empreendimento, nos termos do art. 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538, de 05.03.2008, bem como solicitou, dentre outras informações: (i) as datas de início e de paralisação da oferta de unidades imobiliárias do Empreendimento, com comprovação de tais informações; e (ii) esclarecimentos sobre os motivos da paralisação da oferta.

10. Em resposta¹⁵, refutando a existência de irregularidades, foi informado que:

- a. A Incorporadora agiu de boa-fé e foi diligente, tendo em vista que suspendeu espontaneamente a venda de unidades autônomas previamente a qualquer atuação da CVM e iniciou processo para obtenção de dispensa de registro da oferta perante a SRE;
- b. O lançamento do Empreendimento ocorreu em 30.09.2013, antes de qualquer manifestação da CVM sobre condo-hotéis, e a venda de unidades foi suspensa em 15.09.2014, em decorrência do recebimento do Ofício CVM/SRE/nº508/2014 (“Ofício Hesa 100”) por outra sociedade do mesmo grupo econômico, a Hesa 100 – Investimentos Imobiliários Ltda. (“Hesa 100”), tendo ocorrido em 30.08.2014 a última alienação anterior;
- c. A Hesa 101, à época das vendas das primeiras unidades autônomas do Empreendimento, entendia que a venda de unidades de condo-hotéis, não se enquadrava como oferta de valores mobiliários;
- d. O Alerta ao mercado publicado pela CVM em 12.12.2013 (“Alerta ao Mercado”), em sua página na Internet, não poderia ser considerado como uma indicação à Incorporadora do entendimento da CVM sobre condo-hotéis e seu texto não englobava estruturas como a do Empreendimento, pois se referia à captação de recursos “direcionados a sociedades em conta de participação (SCP), por meio de frações ideais de imóveis que correspondem a cotas das sociedades”;

¹³ Ofício nº 480/2015/CVM/SRE/GER-2, Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524752, fls. 2.314-2.315.

¹⁴ Ofício nº 82/2018/CVM/SRE/GER-3, Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0485560.

¹⁵ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI. 0508240.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

- e. O Empreendimento era formado por unidades autônomas, com registros individualizados perante o Registro de Imóveis, e não envolvia a venda de frações ideais de imóveis. Logo, tratava-se de uma incorporação imobiliária, e não da operação referida no Alerta ao Mercado; e
- f. A Incorporadora não vendeu unidades autônomas entre setembro de 2014 e a data do deferimento da dispensa de registro de oferta pública de valores mobiliários.

III. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO ANTERIOR A ESTE PAS

- 11. No dia 16.05.2018, foi apresentada proposta de termo de compromisso¹⁶, que abarcava um outro PAS e dois processos de investigação envolvendo ofertas públicas irregulares de CICs hoteleiros referentes a empreendimentos que tinham como incorporadoras empresas do mesmo grupo da Hesa 101, entre esses incluía o arquivamento do Processo CVM SEI nº 19957.007000/2016-35, antes da eventual instauração deste PAS, mediante o pagamento do montante de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pela Hesa 101, e de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em relação a seus administradores, representados por Henry Borenstein.
- 12. No entanto, em 01.10.2018, os proponentes comunicaram ao Comitê de Termo de Compromisso sua desistência¹⁷ em celebrar termo de compromisso com a CVM, em razão do julgamento do PAS CVM SEI nº 19957.008081/2016-91, concluído em 07.08.2018.

IV. ACUSAÇÃO

- 13. Com base nos fatos apurados, a SRE elaborou termo de acusação, no qual foram elencadas todas as normas atinentes à acusação, a saber: (i) art. 2º¹⁸, inciso IX, e art. 19, §1º¹⁹, §3º, incisos I a III²⁰, e §5º, incisos I e II, alíneas “a” a “d”²¹, todos da Lei nº 6.385/76; e (ii) arts. 2º, 4º,

¹⁶ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0521915.

¹⁷ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0614257.

¹⁸ Art. 2º São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.

¹⁹ Art. 19. Nenhuma emissão pública de valores mobiliários será distribuída no mercado sem prévio registro na Comissão. § 1º - São atos de distribuição, sujeitos à norma deste artigo, a venda, promessa de venda, oferta à venda ou subscrição, assim como a aceitação de pedido de venda ou subscrição de valores mobiliários, quando os pratiquem a companhia emissora, seus fundadores ou as pessoas a ela equiparadas.

²⁰ Art. 19. (...) § 3º - Caracterizam a emissão pública: I - a utilização de listas ou boletins de venda ou subscrição, folhetos, prospectos ou anúncios destinados ao público; II - a procura de subscritores ou adquirentes para os títulos por meio de empregados, agentes ou corretores; III - a negociação feita em loja, escritório ou estabelecimento aberto ao público, ou com a utilização dos serviços públicos de comunicação.

²¹ §5º - Compete à Comissão expedir normas para a execução do disposto neste artigo, podendo: (...) II - fixar o procedimento do registro e especificar as informações que devam instruir o seu pedido, inclusive sobre: a) a companhia emissora, os empreendimentos ou atividades que explora ou pretende explorar, sua situação econômica e financeira, administração e principais acionistas; b) as características da emissão e a aplicação a ser dada aos recursos dela



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

56-B²² e 59, inciso II²³, da ICVM nº 400/2003, ressaltando, ainda, que, à época da oferta, não existia instrução específica regulando as ofertas públicas de distribuição de CICs hoteleiros²⁴.

14. Na sequência, a Acusação explicitou as diferenças entre o presente PAS e os PASs SEI nº 19957.008081/2016-91 e nº 19957.003266/2017-90²⁵, que trataram de ofertas de CICs hoteleiros, que tinham como incorporadoras outras Sociedades de Propósito Específico (“SPEs”) controladas pela Setin Incorporação e Participação S.A. e uma *joint venture* denominada Hesa 84 Investimentos Imobiliários Ltda.²⁶, destacando inclusive, trechos do voto proferido pelo Diretor Henrique Machado, que prevaleceu no julgamento do Processo CVM SEI nº 19957.008081/2016-91. Nos trechos referidos pela Acusação, foi destacada a publicidade dada ao assunto, a partir de abril de 2014, pela imprensa e setores significativos do mercado imobiliário.

15. Em tal precedente, não foram aplicadas punições por ofertas de CIC hoteleiro realizadas no período compreendido entre o Alerta ao Mercado emitido 12.12.2013 e o recebimento pelos referidos ofertantes do primeiro ofício da SRE, no caso, em maio de 2014, alertando sobre a possibilidade de o investimento ofertado se enquadrar no conceito de valor mobiliário.

16. Porém, a Acusação pontuou que tal caso não se assemelharia ao presente uma vez que a Hesa 101 continuou ofertando os CICs²⁷, tanto após o Alerta ao Mercado, quanto após a repercussão na imprensa e nas entidades de classe do mercado imobiliário sobre o enquadramento dos contratos de condo-hotéis no conceito de valor mobiliário.

17. A SRE apontou também como diferença o fato de a Hesa 101 ter como sócia a Helbor Empreendimentos S.A. (“Helbor”), companhia aberta com registro na CVM e ações negociadas em bolsa, e que tem como Presidente e Diretor os acusados Henry Borestein e Henrique Borestein, que, por atuarem no mercado de valores mobiliários, não poderiam alegar desconhecimento dos alertas divulgados pela CVM.

18. Quanto à materialidade da infração, a SRE destacou que a Hesa 101 utilizou materiais publicitários²⁸ para ofertar os CICs relativos ao Empreendimento, o que já caracterizaria a ocorrência de distribuição pública, nos termos da legislação/regulamentação.

provenientes; c) o vendedor dos valores mobiliários, se for o caso; d) os participantes na distribuição, sua remuneração e seu relacionamento com a companhia emissora ou com o vendedor.

²² Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.

²³ Art. 59. Considera-se infração grave, para os efeitos do §3º do Art. 11 da Lei nº 6.385, de 1976, sem prejuízo da multa de que trata o §1º do mesmo artigo, a distribuição: (...) II - realizada sem prévio registro ou dispensa da CVM;

²⁴ Tal fato ocorreu com a edição da Instrução CVM nº 602, de 27 de agosto de 2018.

²⁵ Nesse PAS foi acusado apenas a pessoa física administradora das incorporadoras responsáveis pelas ofertas.

²⁶ Ambos tiveram julgamento pela CVM iniciado em 10.04.2018 e concluído em 07.08.2018.

²⁷ Visto que o Empreendimento teve vendas até agosto de 2014.

²⁸ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0508242 – Anexo IV.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

19. Além disso, analisando o quadro resumo do Contrato de Promessa de Venda e Compra²⁹, o próprio Contrato de Promessa de Venda e Compra³⁰ e o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação (“Contrato de SCP”)³¹, a Acusação, seguindo o paradigma estabelecido na decisão do Colegiado de 22.01.2008, relativa ao Processo CVM nº RJ2007/11593, destacou, que a proposta de investimento no Empreendimento reuniria todas as características de valor mobiliário, nos termos do inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/1976.

20. Segundo a Acusação, havia investimento uma vez que os adquirentes, ao comprar uma unidade autônoma condo-hoteleira pelo preço ajustado³², aplicavam recursos financeiros. A intenção de se lucrar restaria clara na previsão de distribuição de rendimentos³³ e no interesse do adquirente da unidade autônoma na geração de renda decorrente dos aluguéis e dividendos da SCP.

21. Ademais, a SRE argumentou que o investimento era coletivo, por ser oferecido ao público em geral por meio de material publicitário. As unidades autônomas condo-hoteleiras do Empreendimento foram adquiridas por diversos investidores e o empreendimento hoteleiro era administrado pela AHI através de um único *Pool* obrigatório, conforme os contratos relacionados.

22. A área técnica consignou ainda que havia promessa de remuneração aos adquirentes na forma de dividendos decorrentes da participação no lucro líquido operacional da SCP³⁴ ou da locação das unidades autônomas imobiliárias³⁵. Tal remuneração era oriunda dos esforços de terceiros: a AHI, pois os investidores, após adquirirem as unidades autônomas e aderirem ao *pool* regulado no Contrato de SCP, deveriam entregá-las à operadora hoteleira³⁶.

23. Com base nas informações prestadas pela Incorporadora, que forneceu a relação de investidores do Empreendimento³⁷, informando a comercialização de 153 unidades entre 30.09.2013 e 30.08.2014, sendo 25 após o Alerta ao Mercado, a Acusação consolidou o seguinte quadro resumo:

²⁹ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 76 a 86.

³⁰ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 16 a 73.

³¹ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 131 a 155.

³² Conforme item 04 do quadro resumo do Contrato de Promessa de Venda e Compra, Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 77.

³³ Conforme itens V.1.e V.1.1, do Contrato de SCP, Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls.138-139.

³⁴ Conforme itens V.1 e IX.1 do Contrato de SCP, Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 138, 139 e 142.

³⁵ Conforme item V.1.1 do Contrato de SCP Processo, SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls.139.

³⁶ Conforme itens 8.2 e 8.2.1 do quadro resumo do Contrato de Promessa de Venda e Compra e item II.3 do Contrato de SCP, Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 80 e 136.

³⁷ Doc. SEI. 0508242 – Anexo II.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Período	CICs Comercializados
Até 12/12/2013	128
Entre 13/12/2013 e 31/01/2014	9
fev/14	8
mar/14	3
abr/14	0
mai/14	1
jun/14	0
jul/14	0
ago/14	4
Total	153

24. A Acusação frisou ainda que, ao avaliar consulta da SRE sobre as ofertas de CIC hoteleiros e o Alerta ao Mercado, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) assim se manifestou no PAS CVM SEI nº 19957.008131/2016-30, através do Parecer nº 00182/2016/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU³⁸:

Portanto, se era admissível que os participantes do mercado imobiliário, por não serem agentes que usualmente atuavam no específico mercado de valores mobiliários, não alcançavam o entendimento de que o modelo idealizado para os contratos de condo-hotéis se encaixavam no conceito de valor mobiliário, tal argumento deixou de ser invocável a partir dos referidos Alertas - em especial o Alerta geral - com a divulgação do entendimento da Autarquia.

Neste ponto, nos parece indiscutível que a emissão de tais alertas teve sim o condão de disseminar o entendimento da Autarquia sobre a configuração dos contratos de condo-hotéis como valor mobiliário, bem como sobre a respectiva necessidade de registro prévio das ofertas públicas, não apenas para os agentes que regularmente atuam no mercado de valores mobiliários, mas para toda a sociedade, inclusive aos participantes do mercado imobiliário, como incorporadores e corretores de imóveis. Essa disseminação foi ampliada e multiplicada com a veiculação de notícias sobre o Alerta em diversos meios de comunicação, atingindo, portanto, um número ainda maior de pessoas.

25. Apontou a Acusação que a caracterização dos contratos de condo-hotéis como valor mobiliário foi disseminada não somente por meio de jornais como Valor Econômico³⁹ e O Estado de São Paulo⁴⁰, como também foi amplamente debatida pelas entidades de classe dos mercados

³⁸ Doc. SEI 0206830.

³⁹ Matérias com os títulos “Empresa contesta valor fixado para patrimônio”, “CVM analisa vendas de cotas de hotéis”, “Devagar com esse hotel” e “Investidor consegue recuperar no Judiciário prejuízo com flat”, veiculadas entre 21.05.2014 e 11.08.2014 (Processo SEI 19957.007969/2016-14, Docs. SEI 0526686, 0526688, 0526690 e 0526693).

⁴⁰ Matéria “Incorporadoras e corretoras na mira da CVM” veiculada em 02.04.2014 (Processo SEI 19957.007969/2016-14, Doc. SEI 0526698).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

imobiliário e hoteleiro após a publicação do Alerta ao Mercado⁴¹. Como, por exemplo, o SECOVI (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais), sendo que a Helbor era associada do SECOVI-SP⁴².

26. Segundo a SRE, não seria crível que os administradores da Hesa 101, que também eram administradores de companhia aberta, não tenham recebido informações sobre o Alerta ao Mercado, e não soubessem, até setembro de 2014, do entendimento da CVM de que os contratos de condo-hotéis se encaixavam no conceito de valor mobiliário, assunto que foi amplamente comentado na imprensa e amplamente debatido pelas entidades de classe do mercado imobiliário.

27. Prosseguiu alegando que tanto nos contratos principais, como, por exemplo, o Contrato de Promessa de Venda e o Contrato de SCP, quanto nos contratos secundários, havia informações claras e precisas que permitiam a percepção de que se tratavam de contratos de condo-hotéis.

28. Para a Acusação, os ofertantes assumiram o risco de serem responsabilizados pelas infrações à legislação vigente quando ofertaram unidades do Empreendimento antes da obtenção de registro ou dispensa do registro, somente cessando a oferta quando do recebimento de notificação formal por outra empresa do grupo Helbor.

29. Por fim, a Acusação pontuou que a aquisição de uma unidade condo-hoteleira do Empreendimento acarretava na adesão pelo investidor ao sistema de exploração hoteleira conjunta, regulado pelo Contrato de SCP, o que o qualificava como sócio participante daquela sociedade e vinculava a compra de uma unidade à locação para a exploração pela Operadora Hoteleira.

30. Acerca da responsabilidade da Hesa 101 pela oferta, a SRE destacou que: (i) a própria Incorporadora se apresentou como “Ofertante” no pedido de dispensa de registro e contratou a AHI para fazer a administração de todas as unidades autônomas hoteleiras do condo-hotel; (ii) os materiais publicitários⁴³ utilizados na oferta traziam o logotipo da Helbor, controladora da Hesa 101; e (iii) a Incorporadora era parte nos principais contratos que compunham o CIC relativo ao Empreendimento: promitente vendedora no Contrato de Promessa de Compra e Venda⁴⁴ e sócia participante no Contrato de SCP⁴⁵.

31. Assim, entendeu que a Hesa 101 deve ser responsabilizada pela oferta por meio da divulgação de material publicitário do Empreendimento antes da concessão da dispensa de registro, bem como Henrique Borenstein e Henry Borenstein, tendo em vista serem os

⁴¹ Como, por exemplo, a matéria da “Revista Hotéis” com o título “Regulamentação de condo-hotel pela CVM é debatido na Convenção do SECOVI”.

⁴² Processo SEI 19957.007969/2016-14, Doc. SEI 0526732.

⁴³ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0508242 – Anexo IV.

⁴⁴ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 16.

⁴⁵ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 131.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

administradores da Hesa 101, conforme seu Contrato Social⁴⁶ e cadastro na Receita Federal⁴⁷ e por terem se envolvido diretamente com a oferta em diversas ocasiões, tais como descritas no item 58 do termo acusação, segundo o qual:

- (a) Ambos assinaram a Declaração de Veracidade referente à oferta de CIC do Empreendimento⁴⁸;
- (b) Henry Borenstein assinou: o Acordo Comercial para Administração de Empreendimento Condo-hoteleiro⁴⁹; o Contrato de Prestação de Serviços de Administração Condominial de Natureza Hoteleira⁵⁰; e o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação⁵¹;
- (c) Henrique Borenstein assinou: o 1º Termo de Rerratificação e Consolidação do Anexo 7 do Contrato de Constituição de SCP – Contrato de Locação⁵²; o 1º Termo de Rerratificação e Consolidação Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Administração Condominial de Natureza Hoteleira⁵³; o 1º Termo de Rerratificação e Consolidação do Contrato de Comodato de Áreas e Equipamentos⁵⁴; e o Primeiro Aditivo e Consolidação ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação Equipamentos⁵⁵.

V. RESPONSABILIDADES

32. Diante do exposto, a SRE responsabilizou os Acusados pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003, o que constitui infração grave, consoante o art. 59, II, dessa Instrução.

VI. MANIFESTAÇÃO DA PFE

33. Em 19.11.2018, a PFE manifestou-se no sentido de terem restado atendidos os requisitos previstos nos arts. 6º e 11, da Deliberação CVM nº 538/2008⁵⁶, bem como, diante da existência de indícios de crime de ação penal pública, e recomendou o envio de comunicação ao Ministério Público Federal, o que ocorreu com o envio do Ofício nº 49/2019/CVM/SGE, de 15.02.2019⁵⁷.

⁴⁶ Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524723, fls. 445-459 e Doc. SEI 0508242, Anexo V.

⁴⁷ Doc. SEI 0539036.

⁴⁸ Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524723, fls. 237.

⁴⁹ Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0508242, Anexo III.

⁵⁰ Idem.

⁵¹ Idem.

⁵² Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524728, fls. 815.

⁵³ Idem, fls. 834.

⁵⁴ Idem, fls. 843.

⁵⁵ Idem, fls. 869.

⁵⁶ Doc. SEI 0648500.

⁵⁷ Doc. SEI 0692608.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

VII. RAZÕES DE DEFESA

34. Em 01.04.2019, os Acusados apresentaram, tempestivamente, defesa conjunta⁵⁸ (“Defesa”), na qual não contestaram que os investimentos ofertados relativos ao Empreendimento sejam o que se convencionou chamar de condo-hotéis, os quais, posteriormente, vieram a ser classificados como valores mobiliários, na modalidade CICs, atraindo a competência da CVM.

35. Segundo a Defesa, entretanto, não seria possível punir os Acusados, pois eles suspenderam voluntariamente a oferta assim que a Hesa 100 Investimentos Imobiliários Ltda. (“Hesa 100”) recebeu notificação⁵⁹ da CVM, indicando que o investimento, nos moldes em que ofertado (unidades autônomas), também configuraria CIC.

36. Ainda de acordo com a Defesa, os precedentes do Colegiado existentes até a apresentação do termo de acusação também indicavam, consistentemente, a impossibilidade de punição. Nesse sentido, a Defesa pontuou que, no primeiro julgamento pela CVM de PAS que versava sobre oferta irregular de condo-hotéis, em 07.08.2018⁶⁰, o Colegiado reconheceu que, após a divulgação do Alerta ao Mercado, deveria “*ser considerado um período de assimilação, pelo mercado, do novo posicionamento do regulador.*”. Assim, e considerando que naquele precedente o período da oferta estava compreendido entre a divulgação do Alerta ao Mercado e o recebimento pela incorporadora⁶¹ do primeiro ofício da CVM questionando sua realização e alertando que tal ato poderia configurar uma oferta irregular de valor mobiliário, não houve aplicação de qualquer sanção pelas ofertas de valores mobiliários sem registro ou dispensa no precedente em questão.

37. Além disso, a Defesa destacou que, após esse primeiro precedente, foram julgados outros oito casos⁶², não havendo condenação por ofertas posteriores ao Alerta ao Mercado sem que a incorporadora tivesse sido questionada pela CVM sobre a realização da oferta⁶³. Ademais, ressaltou que há ao menos um caso⁶⁴, em que foi aplicada pena de advertência, mas não devido a

⁵⁸ Doc. SEI 0726780.

⁵⁹ Ofício/CVM/SRE/Nº508/2014.

⁶⁰ PAS CVM nº RJ2016/8347, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 07.08.2018.

⁶¹ No caso em tela, o primeiro ofício foi recebido em 14.05.2014, data que foi considerado o marco temporal a partir do qual, no caso, a incorporadora já não mais poderia ofertar publicamente unidades em condo-hotéis.

⁶² PAS CVM nº RJ2017/1239, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 07.08.2018; PAS CVM nº RJ2018/324, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4779, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 11.12.2018; PAS CVM nº RJ2017/5471, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 11.12.2018; PAS CVM nº RJ2018/157, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 08.01.2019; PAS CVM nº RJ2018/3285, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 29.01.2019; PAS CVM nº RJ2017/5788, Dir. Rel. Carlos Rebello, j. em 29.01.2019; e PAS CVM nº RJ2017/3091, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 26.03.2019.

⁶³ O período de assimilação teria tido fim em 17.03.2015, com a edição da Deliberação CVM nº 734. Ofertas realizadas após essa data, mesmo sem a notificação do incorporador, ensejariam a aplicação de sanção. Entretanto, a Hesa 101 não teria realizado qualquer oferta ou venda após tal data.

⁶⁴ PAS CVM nº RJ2017/5471, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. em 11.12.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

vendas realizadas ao longo de 2014, e sim às realizadas pela incorporadora após a data do recebimento do primeiro ofício da CVM, no referido caso, em 06.03.2015⁶⁵.

38. Complementou alegando que em nenhum dos precedentes já julgados pelo Colegiado houve a condenação a sanção por oferta de condo-hotéis realizada antes da Deliberação CVM nº 734, de 17.03.2015, sem que houvesse “*elemento de prova concreto*” do conhecimento pela incorporadora do entendimento da CVM.

39. Nesse passo, os Acusados sustentaram que o presente caso se amolda exatamente aos precedentes em que não foram aplicadas punições pela CVM.

40. Arguiu a Defesa que, no período das alienações das unidades destacadas pela SRE, a Incorporadora interpretava legitimamente que o Alerta ao Mercado não abarcava a estrutura jurídica do Empreendimento, que apresentava relevantes diferenças com relação à compra e venda de frações ideais de imóveis mencionadas no Alerta ao Mercado, que não teve o condão de obrigar a paralisação da venda de unidades, conforme já decidido pelo Colegiado da CVM:

[O] processo de suspensão deve ser próprio e específico, de modo que o Alerta geral dirigido ao mercado, informando a respeito da necessidade de cumprimento da legislação pertinente, não pode ser considerado como fato gerador da suspensão de toda e qualquer oferta irregular de CIC envolvendo condo-hotel. Logo, o Alerta não teve o condão de suspender a distribuição realizada pelas Recorrentes.⁶⁶

41. Nessa linha, reproduziu trecho do voto do Presidente Marcelo Barbosa no PAS CVM SEI nº 19957.010212/2017-81, julgado em 11.12.2018, em que tratou do período de incerteza existente entre o Alerta ao Mercado e a Deliberação CVM nº 734/15, tendo aduzido que foi a referida Deliberação que estabeleceu regras claras e objetivas sobre a dispensa de registro dos CICs hoteleiros, não deixando margem para dúvida quanto ao entendimento da CVM, e que mesmo após o Alerta ao Mercado não é possível exigir uma assimilação automática da interpretação da CVM a respeito da natureza dos CICs hoteleiros, tratando-se de setor que até então havia permanecido alheio à regulação do mercado de valores mobiliários.

42. O contexto em que as manifestações da CVM ocorreram também foi destacado pelos Acusados, que lembraram que as ofertas de condo-hotéis, além de estarem sujeitas a regramento próprio, ocorriam há décadas⁶⁷, e em todo esse período, a CVM não havia manifestado seu

⁶⁵ A Defesa sublinha que conforme o item 12 do relatório de tal caso, foram vendidas 18 unidades em novembro de 2014, quatro em dezembro de 2014 e cinco em janeiro de 2015, mas a venda dessas 27 unidades antes do recebimento do ofício pela incorporadora não embasou a aplicação de qualquer sanção.

⁶⁶ Trecho apontado pela Defesa (Doc. SEI 0726780, fls. 12) com relação ao voto do ex-Presidente da CVM, Leonardo Pereira, no Processo CVM SEI nº 19957.004122/2015-99, decidido em 12.04.2016.

⁶⁷ Inclusive, eram anteriores a previsão legal dos CICs.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

entendimento quanto à sua competência de supervisão sobre tal estrutura. Tal pronunciamento, sustenta a Defesa, era vital, tendo em vista que o conceito de valor mobiliário foi introduzido de forma aberta no ordenamento jurídico. Portanto, era cabível a interpretação de que sua venda não estaria sujeita a supervisão e fiscalização da CVM.

43. Os Acusados acrescentaram, ainda, que o entendimento da CVM sobre o assunto foi se alterando ao longo do tempo, devido a melhor compreensão pela CVM da atividade de incorporação imobiliária. Como exemplo, foi mencionado que a SRE, originalmente, concedia dispensa de registro de oferta tão somente para as unidades disponíveis para venda, o que foi posteriormente alterado para abarcar, também, as unidades autônomas vendidas, mas que viessem a retornar, por distrato, ao estoque da incorporadora. De igual modo, o Colegiado afastou a antiga exigência de se assegurar aos antigos adquirentes o direito de retratação das vendas feitas até abril de 2016, por reconhecer a incerteza da regulamentação aplicável.

44. Frisaram, também, que a própria ICVM nº 602, de 27.08.2018, atualizou o tratamento dos condo-hotéis, refletindo entendimentos que até então não haviam sido divulgados pela CVM, como por exemplo, que as operadoras hoteleiras, a princípio, não são ofertantes dos CICs.

45. A Defesa igualmente se insurgiu contra o que entendeu ser a imposição de tratamento diferenciado à Incorporadora, negando-lhe o “período de assimilação” considerado nos precedentes, pelo simples fato de sua controladora ser uma empresa de capital aberto, “não se justifica sob nenhuma ótica”, visto que as incertezas em torno do teor do Alerta CVM eram as mesmas para todo o mercado imobiliário, independentemente da estrutura de capital das empresas.

46. Ademais, a Defesa arguiu que todas as condenações impostas pela CVM até então foram calcadas no recebimento de ofício emitido pela SRE, ou ainda, pelo seguimento da oferta após a Deliberação CVM nº 734/2015, não havendo precedente onde a estrutura da incorporadora ou a formação profissional dos administradores justificasse a aplicação de sanção.

47. Nesse contexto, as imputações por ofertar CICs Hoteleiros em período anterior ao envio do Ofício Hesa 100 pela SRE importariam em aplicação retroativa de nova interpretação de norma administrativa, o que é vedado pelo art. 2º, § único, XIII da Lei nº 9.784, de 29.01.1999⁶⁸.

48. No mesmo sentido, sustentaram os Acusados que o fato de o conceito de contrato de investimento coletivo ter sido incluído no nosso ordenamento jurídico como um conceito aberto

⁶⁸ Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. (...) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

combinado com a ausência de clara manifestação da CVM sobre o tema até a edição da Deliberação CVM nº 734/2015, faz com que a sanção por eventuais irregularidades anteriores seja obstada pela excludente de ilicitude do erro de proibição, como foi já foi reconhecido pelo Colegiado da CVM no julgamento dos casos relativos à “crise da marcação a mercado”.

49. A Defesa também refutou a tese da SRE de que os Acusados já tinham ciência da irregularidade da oferta antes do recebimento do Ofício Hesa 100 pela respectiva incorporadora. Especificamente sobre a convenção do SECOVI, de 28.08.2014, que teria tratado do tema, foi afirmado que nenhum dos Acusados ou seus representantes estavam presentes em tal evento.

50. Por fim, a Defesa sustentou que, ainda que se conclua pela responsabilidade da Incorporadora, não caberia apenas seus administradores com base em assinaturas de contratos, cujas celebrações foram todas anteriores ao Alerta ao Mercado. Além disso, os Acusados sustentam que a Acusação não teria demonstrado que eles tinham competências legais e estatutárias relacionadas com a oferta dos CICs, consoante o art. 56-B da ICVM nº 400/2003.

VIII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

51. Em reunião do Colegiado ocorrida em 21.05.2019, fui sorteada relatora deste processo⁶⁹. É o relatório.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2020.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

⁶⁹ Doc. SEI 0761915.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR SEI Nº 19957.009556/2018-28

(PAS CVM nº RJ2018/7211)

Reg. Col. 1402/19

Acusados: HESA 101 – Investimentos Imobiliários Ltda.
Henrique Borenstein
Henry Borenstein

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela realização de oferta pública de CICs hoteleiros sem a obtenção de registro ou dispensa.

Diretora Relatora: Flávia Perlingeiro

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SRE em face da incorporadora Hesa 101 e de seus administradores, Henrique Borenstein e Henry Borenstein, para apurar eventual responsabilidade pela realização de oferta pública de CICs relativos ao empreendimento hoteleiro **Park Inn by Radisson Santos**, sem a obtenção do registro de que trata o art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e o art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM 400/2003.

2. Neste PAS, julgamos se cabe responsabilizar os Acusados pela realização de oferta pública de CICs hoteleiros relativos ao Empreendimento enquanto inexistentes o registro ou a dispensa de registro perante a CVM (“Oferta Irregular”), no período decorrido antes da obtenção da respectiva dispensa de registro concedida pela CVM, em 18.12.2015. Cabe observar, de plano, que consoante reconhecido pelos próprios Acusados, 25 unidades autônomas componentes do Empreendimento foram alienadas após o Alerta ao Mercado de 12.12.2013, sendo que entre essas apenas **cinco** foram vendidas entre maio e setembro de 2014, quando outra empresa do grupo recebeu Ofício da SRE², e que nenhuma unidade foi alienada de setembro de 2014 até a data de obtenção da dispensa de registro neste caso.

3. Destaco também, desde já, a relevância, para o deslinde deste caso, do julgamento do PAS CVM SEI nº 19957.009570/2018-21, ocorrido em 10.12.2019, de relatoria do Diretor

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).

² Trata-se do Ofício/CVM/SRE/Nº 508/2014, de 15.09.2014, recebido pela HESA 100 – Investimentos Imobiliários Ltda. (“Hesa 100”), Doc. SEI 0726780, fls. 37-38.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Henrique Balduino Machado (“Precedente Hesa 112”), em que foram condenados outra sociedade de propósito específico integrante do grupo Helbor – a Hesa 112 - Investimentos Imobiliários – e seus administradores³ também acusados neste PAS, por oferta irregular de CICs hoteleiros referentes a outro empreendimento hoteleiro.

4. Como detalharei mais adiante, no Precedente Hesa 112, assentou-se o entendimento deste Colegiado acerca de certos aspectos relevantes para a análise da responsabilização dos acusados, os quais, a meu ver, são igualmente aplicáveis neste processo.

II. MATERIALIDADE

5. Em benefício da síntese, haja vista a consolidada posição do Colegiado da CVM em diversos precedentes sobre o tema⁴, deixo de repisar o debate acerca da caracterização do condo-hotel como CIC e da consequente necessidade de registro ou dispensa de registro perante a CVM para a realização de oferta pública de distribuição, nos termos da Lei nº 6.385/1976 e da regulamentação aplicável.

6. Neste PAS, a Acusação demonstrou a existência dos CICs, nos termos previstos no inciso IX do art. 2º da Lei nº 6.385/76⁵, ao evidenciar que os contratos eram coletivos, previam remuneração para os investidores, advinda de esforços empreendidos por terceiros e que foram ofertados publicamente, inclusive por meio de materiais publicitários divulgados em *websites*.

7. Os defendentes, por sua vez, não trouxeram qualquer argumento ou prova a demonstrar que os contratos referentes ao Empreendimento se distinguem daqueles utilizados em outros empreendimentos hoteleiros já examinados pela CVM. Os próprios documentos e informações que, posteriormente, vieram a embasar a dispensa de registro perante a CVM evidenciam a configuração dos CICs e a Oferta Irregular durante o período que antecedeu a referida dispensa, não havendo razão para reabrir a discussão já superada.

8. Assim, os fatos examinados neste PAS, em seus aspectos fundamentais, se coadunam com os precedentes julgados pela CVM, restando, a meu ver, bem caracterizada a infração.

III. ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE

9. Também considero que restou bem demonstrada a responsabilidade da Hesa 101 pela Oferta Irregular de CICs do Empreendimento, inclusive por meio dos materiais publicitários utilizados⁶ que traziam a logomarca da Helbor, controladora da Hesa 101.

³ Henry Borenstein e Henrique Borenstein.

⁴ v., p.ex., PAS CVM nº RJ2017/2225, j. 28.08.2018; PAS CVM nº RJ2018/324, j. 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4412, j. 30.10.2018; PAS CVM nº RJ2017/4779, j. 11.12.2018; e PAS nº RJ2017/3091, j. 26.03.2019.

⁵ v. Decisão de 15.01.2008, no âmbito do Processo CVM nº RJ2007/11593, Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto.

⁶ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0508242 - Anexo IV.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

10. Ademais, a Incorporadora era parte em dois dos contratos centrais que compunham os CICs: (i) como “Promitente Vendedora” no Contrato de Promessa de Compra e Venda⁷; e (ii) como sócia participante no Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação⁸; bem como se identificou como ofertante no pedido de dispensa de registro perante a CVM⁹.

11. Da mesma forma, foi comprovado o envolvimento direto de Henry Borenstein e Henrique Borenstein com a Oferta Irregular, por sua atuação como administradores da Incorporadora, conforme demonstrado no Contrato Social e no cadastro na Receita Federal da Hesa 101¹⁰, reforçado pelo fato de que representaram a Incorporadora na assinatura de diversos documentos atinentes ao Empreendimento, observando-se que: (i) ambos os Acusados assinaram a Declaração de Veracidade referente à oferta de CICs do Empreendimento¹¹; (ii) Henry Borenstein assinou o Acordo Comercial para Administração de Empreendimento Condo-hoteleiro¹², o Contrato de Prestação de Serviços de Administração Condominial de Natureza Hoteleira¹³, e o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação¹⁴; e (iii) Henrique Borenstein assinou o 1º Termo de Rerratificação e Consolidação do Anexo 7 do Contrato de Constituição de SCP – Contrato de Locação¹⁵, o 1º Termo de Rerratificação e Consolidação Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Administração Condominial de Natureza Hoteleira¹⁶; o 1º Termo de Rerratificação e Consolidação do Contrato de Comodato de Áreas e Equipamentos¹⁷, e o Primeiro Aditivo e Consolidação ao Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de Participação Equipamentos¹⁸. Observe-se que este PAS se originou do pedido de dispensa protocolado pela Incorporadora, do qual constavam esses documentos utilizados pela Acusação para demonstrar a materialidade e autoria da infração, o que cabe ser sopesado para fins de dosimetria.

12. Note-se, ainda, como igualmente apontado pela Acusação, que a responsabilidade dos administradores da ofertante é expressamente prevista no art. 56-B da ICVM nº 400/2003¹⁹.

⁷ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 16.

⁸ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 131.

⁹ Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524722, fls. 1-14.

¹⁰ Processo SEI 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524723, fls. 444-456 e Doc. SEI 0539036.

¹¹ Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524723, fls. 237.

¹² Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0508242, Anexo III.

¹³ Idem.

¹⁴ Idem.

¹⁵ Processo SEI nº 19957.007000/2016-35, Doc. SEI 0524728, fls. 815.

¹⁶ Idem, fls. 834.

¹⁷ Idem, fls. 843.

¹⁸ Idem, fls. 869.

¹⁹ Art. 56-B. Os administradores do ofertante, dentro de suas competências legais e estatutárias, são responsáveis pelo cumprimento das obrigações impostas ao ofertante por esta Instrução.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

13. Resta analisar o grau de reprovabilidade das condutas dos Acusados, à luz dos marcos temporais estabelecidos²⁰ e consolidados pelo Colegiado em diversos julgados nos últimos anos.

14. Para tanto cabe repisar que o entendimento do Colegiado tem sido no sentido (i) da não responsabilização pelos atos de distribuição realizados antes de 12.12.2013, data da divulgação do Alerta ao Mercado, ocasião em que a CVM manifestou-se sobre a caracterização dos chamados condo-hotéis como valores mobiliários na modalidade CIC; (ii) da responsabilização dos atos de distribuição posteriores a 17.03.2015, data da edição da Deliberação CVM nº 734, que estabeleceu requisitos e procedimentos para a obtenção de dispensa de registro de oferta pública desses CICs; e (iii) da necessidade de se sopesar as **particularidades do caso concreto** para os atos ocorridos no **período compreendido no interregno** transcorrido entre tais datas.

15. Neste PAS, consoante as informações trazidas aos autos pelos próprios Acusados, Acusação elaborou a seguinte tabela-resumo constante no item nº 44 do Termo de Acusação:

Período	CICs Comercializados
Até 12/12/2013	128
Entre 13/12/2013 e 31/01/2014	9
fev/14	8
mar/14	3
abr/14	0
mai/14	1
jun/14	0
jul/14	0
ago/14	4
Total	153

16. De pronto, destaco que a SRE acertadamente reconheceu que não cabe responsabilizar os Acusados pela oferta de CICs Hoteleiros relativos ao Empreendimento no período anterior à divulgação do Alerta ao Mercado.

17. Nesse sentido, a acusação repercutiu apenas com relação ao período transcorrido entre 13.12.2013 e agosto de 2014, ao longo do qual foram alienadas 25 unidades autônomas integrantes do Empreendimento, evidenciando que os Acusados ofertaram CICs hoteleiros durante o que se passou a chamar de “período de assimilação”, cabendo ao Colegiado analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de identificar o momento a partir do qual os Acusados não mais poderiam alegar seu desconhecimento acerca do posicionamento da CVM quanto à configuração dos investimentos em condo-hotéis como CICs para justificar a continuidade da oferta.

²⁰ PAS CVM SEI nº 19957.004122/2015-99, j. 12.04.2016, e PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, j. 07.08.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

18. Considerando as semelhanças deste caso com o Precedente Hesa 112, cabe reiterar o entendimento então assentado pelo Colegiado no sentido de que (i) após a primeira manifestação objetiva e institucional da CVM sobre a natureza dos CICs hoteleiros por meio do Alerta ao Mercado de 12.12.2013, seguiu-se, ao longo do chamado “período de assimilação”, e já **a partir do fim do primeiro trimestre de 2014**, a disseminação de matérias a respeito do posicionamento da Autarquia em publicações em portais de comunicação de grande alcance, bem como de discussões e posicionamentos de relevantes entidades do setor imobiliário, e (ii) o alerta **não se restringia apenas a um modelo específico de estruturação de negócio imobiliário**, refutando a alegação de que não estariam abrangidos os empreendimentos estruturados com unidades autônomas, ao contrário do que sustentam os Acusados.

19. Além disso, o Precedente Hesa 112 também deixou clara a percepção do Colegiado no sentido de que, do segundo trimestre de 2014 em diante, a referida difusão do Alerta ao Mercado não passou despercebida dos **grandes players do mercado imobiliário**, como é o caso do grupo Helbor, razão pela qual o Colegiado não acolheu o argumento dos defendentes de que apenas tomaram ciência do entendimento institucional da CVM em setembro de 2014, quando do recebimento do Ofício da SRE. Também foi igualmente refutado pelo Colegiado o alegado erro de proibição quanto à caracterização da oferta pública de valor mobiliário por se tratar de agente integrante de grupo relevante no mercado imobiliário.

20. Tanto a Hesa 101 quanto a Hesa 112 são sociedades de propósito específico controladas pela Helbor Empreendimentos S.A., da qual H.B. e Henry Borenstein são administradores, sendo de todo aplicável o mesmo entendimento neste caso.

21. Como bem pontuado pelo Diretor Henrique Machado no Precedente Hesa 112: a Helbor é “ *um grande player do mercado imobiliário, que está inserido e, portanto, tem familiaridade com a dinâmica de captação de recursos no mercado de valores mobiliários e que não pode alegar desconhecimento da matéria, após a divulgação do alerta pela CVM e a ampla repercussão pública de seu conteúdo após mais de oito meses da divulgação do Alerta ao Mercado.*”.

22. Especificamente sobre a repercussão pública do Alerta ao Mercado, o ilustre Diretor Relator Henrique Machado já havia se manifestado, em 07.08.2018, no julgamento do PAS CVM SEI nº 19957.008081/2016-91, no seguinte sentido:

24. Assim, **a partir de abril de 2014**, a grande imprensa já havia dado razoável publicidade ao assunto e setores significativos do mercado imobiliário dele já tinham conhecimento e estavam, inclusive, externando publicamente seus posicionamentos e discussões sobre o tema. **A difusão do Alerta, portanto, não pode ter passado despercebida, em especial para um grande “player” do mercado imobiliário**, do qual se supõe que tenha acesso às informações atualizadas sobre o seu ramo de atividade e que participe das principais



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

entidades de classe do setor.

.....
29. *Considero, portanto, que a partir do recebimento do recebimento do Ofício nº 259 [de 14.05.2014, que pela primeira vez informou a empresa do Grupo Setin que o investimento ofertado poderia se enquadrar no conceito de valor mobiliário], e não somente a partir da emissão da Deliberação CVM nº 734/15, em 17.03.2015, conforme entende o Relator, já teria se tornado incontroverso e suficientemente assimilado pelas Acusadas o entendimento da Autarquia de que oferta pública de seus condohoteis deveria se submeter às normas de registro, em especial à Instrução CVM nº 400/03.* (grifos adotados)

23. Por fim, destaque-se também a seguinte passagem da manifestação de voto do Presidente Marcelo Barbosa, no âmbito do PAS CVM nº RJ2017/3091, julgado em 21.05.2019:

8. (...) reitero meu posicionamento exposto por ocasião do julgamento do PAS RJ 2017/1298 (em que fui acompanhado pela maioria do Colegiado), no sentido de que a **atuação sancionadora por parte da CVM se justifica independentemente da concessão da dispensa de registro e tem como propósito punir os agentes responsáveis pela inércia em buscar a regularização da oferta junto à CVM, deixando mercado e investidores expostos no período que antecede a concessão da dispensa.** (grifos adotados)

24. Neste PAS, cabe destacar que, conforme indicado no item 35 do Termo de Acusação²¹, foram alienadas **cinco** unidades **após o primeiro trimestre de 2014** e antes da obtenção da dispensa de registro da oferta perante a CVM, tendo uma venda ocorrido em maio e as outras quatro em agosto de 2014, evidenciando, de todo modo, o cabimento da responsabilização dos Acusados com relação a tal período.

IV. DOSIMETRIA E CONCLUSÃO

25. Passo, então, a dosimetria da pena a ser aplicada à Incorporadora e seus administradores.

26. No julgamento dos Processos SEI nºs 19957.0003266/2017-90 e 19957.008081/2016-91, consignou-se que as penalidades a serem cominadas aos responsáveis por ofertas irregulares de CIC hoteleiros sejam aplicadas por oferta, atenuadas ou agravadas em razão do período em que a irregularidade foi praticada e o número de unidades vendidas, o que tem sido adotado nos diversos precedentes julgados desde então, sopesando também o porte do ofertante²².

27. Em que pese a gravidade em abstrato da conduta e o fato de a Incorporadora integrar grupo econômico de grande porte, considero ainda assim que, neste caso, em linha com outros

²¹ Doc. SEI 0619146.

²² Nesse sentido, destaco manifestação de voto do Diretor Henrique Machado, acompanhada pela maioria do Colegiado, no âmbito do PAS CVM nº 19957.008081/2016-91, j. em 07.08.2018, e o voto Diretor Relator Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº RJ2018/2316, j. em 01.10.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

precedentes julgados pelo Colegiado²³, não se justifica a aplicação de penalidade mais gravosa que advertência, notadamente tendo em vista (i) as poucas unidades alienadas após o período de assimilação aplicável neste caso (apenas cinco); e (ii) a suspensão voluntária da Oferta Irregular pela Hesa 101, ainda que após o recebimento de Ofício pela Hesa 100, em setembro de 2014, e a retomada da oferta apenas após obtida a dispensa de registro em dezembro de 2015, período quanto ao qual restou demonstrada boa-fé e empenho da Incorporadora nas interações com a Autarquia voltadas à obtenção da dispensa e ajuste de seus procedimentos às normas aplicáveis²⁴.

28. Pelo exposto, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/1976 (com redação anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13.11.2017), voto pela:

- a. condenação da **Hesa 101 – Investimentos Imobiliários Ltda.**, à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/03;
- b. condenação de **Henry Borenstein** à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003; e
- c. condenação de **Henrique Borenstein** à penalidade de **advertência**, pela realização de oferta pública de distribuição de CICs, sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei nº 6.385/1976 e no art. 2º da ICVM nº 400/2003 e sem a dispensa prevista no art. 19, §5º, I, da Lei nº 6.385/1976 e no art. 4º da ICVM nº 400/2003.

29. Por fim, impende comunicar o resultado deste julgamento ao Ministério Público Federal no Estado de São Paulo, em complemento ao Ofício nº 28/2019/CVM/SGE²⁵, de 31.01.2019.

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2020.

Flávia Sant'Anna Perlingeiro

Diretora Relatora

²³ Em linha com precedentes julgados pela CVM, como, por exemplo, PAS RJ2018/324, Relator Diretor Gustavo Gonzalez, j. 30.10.2018; PAS CVM 19957.010212/2017-81, Relator Presidente Marcelo Barbosa, j. 11.12.2018 e PAS 19957.007937/2016-19 e 19957.004542/2017-37, de minha relatoria, j. em 10.12.2018.

²⁴ Vale destacar disposição da ICVM nº 607, de 17.06.2019 (art. 66, I), quanto a circunstância atenuante relativa a “confissão do ilícito ou a **prestação de informações relativas à sua materialidade**” (grifei).

²⁵ Doc. SEI 0678606.